

1505095-82.2020.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... já decidiu o Tribunal de Justiça, "Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1505095-82.2020.8.26.0309

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1505095-82.2020.8.26.0309

Página nº de

Vistos.

JHEAN LUCA SIQUEIRA PROENÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de agosto de 2020, na Rua Osvaldo Batisteli nº 88, Torres de São José, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a peça inicial que o acusado adquiriu 100 frascos de tamanhos variados de lança-perfume e os armazenou no interior de sua residência.

Na data dos fatos, o réu pegou 20 frascos pequenos e 30 grandes e passou a

transitar pela via pública, na condução de uma bicicleta, visando entregar as drogas em um ponto de venda na Rua Augusto Maia.

Durante o trajeto, guardas municipais avistaram Jhean, que se assustou e tentou fugir, porém sem êxito. Em seu poder os agentes municipais apreenderam uma sacola contendo o entorpecente acima descrito. Logo após, os guardas municipais se dirigiram à residência do acusado, oportunidade em que o cão farejador encontrou outros 50 frascos da mesma droga, que estavam no baú de uma motocicleta.

Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas..

Encerrada a instrução, em debates, a Promotora de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente comprovadas a autoria e a materialidade. Requereu, ainda, a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em preliminar, a juntada de documentos e alegou o que segue: a ilicitude das provas, uma vez que a prisão do réu foi realizada por guardas municipais, os quais não têm legitimidade para efetuar diligências afetas somente à Polícia Judiciária, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal; a nulidade das provas em razão da abordagem pessoal, por violação ao disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser absolvido por ausência de prova lícita. Sustentou, ainda, a absolvição por insuficiência probatória, vez que o silêncio do réu não pode ser considerado em seu desfavor e que as palavras dos guardas municipais devem ser recebidas com reserva. Em caso de entendimento diverso, postulou a fixação da pena-base no patamar legal; afastamento da qualificadora; aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; substituição da corporal por restritivas de direitos; imposição de regime inicial aberto e o direito de recorrer solto.

O réu deixou de entregar os documentos comprobatórios de atividade lícita à Defensoria no prazo deferido. Reiterando a defesa, as alegações finais.

RELATADO.

DECIDO.

As preliminares suscitadas não prosperam.

Não há falar em ilegalidade na atuação dos guardas municipais quando da prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, não houve qualquer investigação policial exercida pelos guardas municipais, mas sim situação de flagrância, o que autoriza a prisão, vez que o tráfico de substância entorpecente é crime de natureza permanente. Assim, permanecendo o agente em situação de flagrância, não há qualquer ilicitude no fato dos guardas municipais terem dado voz de prisão ao acusado e apreendido a droga.

Ademais, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante.

E ainda que se desconsiderasse o enquadramento dos guardas municipais como "autoridades policiais" – a quem cabe o dever de efetuar prisões em flagrante – permaneceria a eles a possibilidade de realizá-las, uma vez que o dispositivo legal acima referido permite, de forma expressa, tal faculdade a "qualquer do povo".

Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "Tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Nulidade do auto de prisão. Flagrante realizado por guardas municipais. Possibilidade. Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal.

Mácula inexistente. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes". (HC nº 296.728/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2014).

Note-se, outrossim, que a prisão foi devidamente comunicada à autoridade judiciária competente, que lavrou o auto de prisão respectivo e firmou a nota de culpa ao réu, ratificando e convalidando, portanto, os atos praticados pelos agentes municipais. Importa observar, por oportuno, embora o disposto no artigo 144, § 8º, da Carta

Magna, disponha como função da guarda municipal – relativamente ao município – a “proteção de seus bens, serviços e instalações”, não existe proibição na prisão em flagrante de pessoas suspeitas por prática de crimes, bem como a apreensão de bens relacionados aos delitos.

Entendimento contrário, como quer a defesa, implicaria equivocada proibição às guardas municipais, sem qualquer base normativa ou justificativa razoável.

Não é caso, outrossim, de nulidade por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio na diligência que culminou com a apreensão do entorpecente, uma vez que se trata de crime permanente, o que afasta qualquer ilicitude na ação dos guardas municipais.

Para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, basta a verificação de apenas uma das figuras constantes no “caput” do artigo 33 da Lei de Drogas especialmente a de ter em depósito substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

Ademais, a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio comporta exceções, como no caso de flagrante delito.

Verdadeiramente, ensina Guilherme de Souza Nucci, “Em casos de crimes permanentes (aqueles que se prolongam no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível” (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., RT, 2008, pág. 530, nº 31).

Em outras palavras, “Por força da ressalva inserida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em residência encontra-se expressamente autorizado, em qualquer dia e horário e independentemente de autorização judicial, quando, em seu interior, encontra-se o denominado estado de flagrância, como na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento” (RT, 764/609).

E mais, “Ilegalidade também não haverá na hipótese em que a “invasão de domicílio” decorrer de diligência iniciada na rua e complementada na residência do acusado, já que a Constituição da República não proíbe a busca e apreensão de coisas por ocasião do flagrante, mantendo sua eficácia o artigo 240 do Código de Processo Penal, que compreende na busca domiciliar tanto a prisão como a apreensão das coisas” (JTJ-SP, 141/403).

Também não há nulidade na abordagem do réu realizada pelos guardas municipais.

Quando esses agentes abordam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem ser omissos diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, “(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, “revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas” (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016).

6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que “tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio”, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que “em processo penal, vigoram os princípios de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)’” (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastadas as preliminares, no mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia deve ser julgada procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 12/16), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o acusado confessou a traficância, afirmando que guardava a droga para “Mateus”. Franqueou a entrada dos guardas municipais em sua residência. Em Juízo, fez uso constitucional do direito de permanecer em silêncio.

No tocante à confissão policial, já decidiu o Tribunal de Justiça, “Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico” (Apelação Criminal n.º, de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. de 08/01/2009).” (Apelação Criminal nº 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016)

E mais, “É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil”. (Apelação Criminal nº 9230875-35.2008.8.26.0000, Rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. de 10/05/2012).

Corroborando a prova de autoria, as testemunhas Monique Effori e Julio César Eneres, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro da substância tóxica em poder do réu, nas proximidades de um estabelecimento de ensino. Esclareceram, ainda, que o acusado confessou informalmente a traficância e informou que armazenava drogas na residência da namorada. A “biqueira” para a qual a droga seria levada pelo acusado estava localizada nas proximidades de uma escola municipal.

As palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação, eis que são depoimentos coerentes, harmônicos e verossímilantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova e para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente o acusado, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, “A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC 74.522-

9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Importante salientar que a prova produzida comprova que o réu trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracterizando o crime a ele imputado e pelo qual deve ser responsabilizado.

Porém, não está demonstrada a causa especial de aumento descrita na denúncia, uma vez que não há prova nos autos que o réu praticou comércio clandestino nas proximidades de estabelecimento de ensino, eis que a denúncia descreve os verbos trazer e guardar, não fazendo qualquer referência à venda. Além disso, o acusado foi detido quando passava pelo local na condução de sua bicicleta.

Nesse sentido, "A interpretação literal e teleológica do referido inciso III, que alude a "dependências" e "imediações" dos locais ali discriminados, revela que o dispositivo busca reprimir com mais intensidade a conduta de quem pratica o tráfico no próprio local em suas instalações ou nas adjacências, isto é, nas cercanias, circunstância que reclama efetiva proximidade, pouca distância, propiciando que o agente tire proveito do fluxo ou circulação das pessoas que frequentam ou visitam aqueles lugares, desautorizando, portanto, a incidência da majorante a hipóteses como a dos autos. No caso, além da significativa distância, não restou evidenciado o intuito de alcançar os transeuntes daquela localidade, até porque ADRIANO não foi flagrado, em atitude suspeita, posicionado estrategicamente para vender entorpecente, mas, sim, trafegando pelo local, de passagem, conduzindo a motocicleta de sua esposa" (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500139-51.2020.8.26.0623, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargador Otávio de Almeida Toledo, j. em 11/12/2020).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, a denúncia e o faço para CONDENAR o réu JHEAN LUCA SIQUEIRA PROENÇA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que as circunstâncias judiciais favorecem o réu.

Ausentes circunstâncias agravantes.

A atenuante da menoridade não pode ser considerada, ante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Possível a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, reduz a pena em 1/2 (metade), a qual se concretiza em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor da lei específica.

Excepcionalmente, por ser primário, poderá cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto, de acordo com a jurisprudência mais recente dos nossos tribunais, sendo possível que apele em liberdade.

Presentes os requisitos legais, substituo a corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a critério do Juiz da execução; limitação de fim de semana e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Assim, fica o réu JHEAN LUCA SIQUEIRA PROENÇA, qualificado nos autos, condenado à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituída a corporal nos termos acima propostos.

P.I.C.

Jundiaí, 3 de junho de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito